

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O § 4º do Art. 37 é muito simples e dispõe sobre a punição dos atos de improbidade administrativa. Quem pratica esse ato pode sofrer a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e pode responder a uma ação penal, caso se configure crime. A ação de improbidade administrativa é uma ação de natureza civil. Dessa forma, tramita na primeira instância, ainda que tenha sido ajuizada contra pessoa que tenha foro especial.

Todos estão sujeitos a serem julgados por improbidade administrativa. Há apenas uma ressalva. Em relação ao Presidente da República, somente ele não se sujeita à Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei é de 1992, mas, em 2021, foi esfacelada, para garantir a impunidade. Aliás, foi nesse cenário que o STF argumentou que o Presidente não responde a essa lei, mas não quer dizer que ele ficará impune no caso de improbidade.

Para o Presidente da República, o Art. 85, inciso V, prevê que atos contra a probidade são respondidos no Senado Federal, por crime de responsabilidade. Há uma discussão sobre se as demais autoridades com foro especial teriam uma dupla punição pelo mesmo fato – a situação de alguém responder por improbidade e por crime de responsabilidade. Hoje, o entendimento que prevalece é que são coisas diferentes e pode-se responder pelos três: crime comum, crime de responsabilidade e por improbidade. Por exemplo, um Ministro de Estado, em um crime comum, vai para o STF. Em um crime de responsabilidade, caso não esteja em conexão com o Presidente ou com o Vice, vai para o STF. Além disso, pode responder por improbidade na primeira instância. Governador, no crime comum, vai para o STJ. No crime de responsabilidade, Tribunal Especial. Ação de improbidade, primeira instância.

Não há foro especial para julgamento de autoridades por ação popular e ação de improbidade administrativa, que é ação civil pública. O legitimado, para entrar com ação que versa sobre improbidade, de acordo com a lei de 2021, seria apenas o Ministério Público. O STF argumentou que deve se dar ao Ministério Público e, também, ao órgão lesado, ao ente que foi prejudicado. Pode ser tanto o MP entrando com a ação quanto também o ente que foi lesado, sem foro especial. Por ação de improbidade, todos são alcançados, até mesmo estagiários.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de **prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente**, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.



Pelo que está escrito, havendo dano aos cofres públicos, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Uma das novidades da legislação de 2021 foi acabar com a improbidade na forma culposa. Existia, na Lei de Improbidade Administrativa, os Arts. 9, 10, 11 e 12, que previam as punições, em uma gradação que vai aumentando a punição. Quem dá o regramento é o Art. 12, mas as condutas chamadas de improbidade na forma culposa não existem mais.

Pelas ações em geral, adota-se o princípio da segurança jurídica e, as ações em geral, prescrevem. Vê-se que o STF excluiu da possibilidade de prescrever a ação de improbidade administrativa. Em 2018, o STF deu uma decisão argumentando que ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos civis prescrevem. Em 2020, o STF disse que, se é decorrente de improbidade na forma dolosa, não prescreve. Se é na forma culposa, aí prescreve. Em 2021, deixa de existir improbidade na forma culposa. Logo, todos que foram condenados por improbidade na forma culposa acabaram “rindo de orelha a orelha”. Em 2022, as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de condenação proferida pelo Tribunal de Contas passaram a prescrever também. Em 2023, o STF disse que, se decorrer de dano ambiental ou de dano decorrente da exploração irregular de patrimônio mineral da União, nesse caso, não prescrevem. Tem-se um cenário de algumas que prescrevem e de outras que não prescrevem. Ilícitos civis prescrevem, bem como condenações proferidas pelo Tribunal de Contas. Nas demais, não prescrevem.



10m

Aprende-se que lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Acontece que, quando se fala de improbidade, há coisas que vieram de forma benéfica. A lei de 2021 tem coisa claramente benéfica. A “malandragem” que fizeram em 2021 era para liberar todo mundo. Veio o STF e disse que, para o que vier no meio do caminho, a resposta é uma e, para o que já estiver julgado, a resposta é outra. Não poderá retroagir para quem tem condenação definitiva. É mais benéfica, mas não é Direito Penal, e sim Direito Administrativo Sancionador. Por outro lado, caso se estivesse respondendo, ou seja, no meio do caminho, nesse caso, a lei nova é aplicável, inclusive em relação a prazos prescricionais. Hoje, não há mais o elemento culpa. Sempre exige o elemento dolo, mas a questão da retroação não alcança quem já teve condenação definitiva.



15m

Deve-se saber os procedimentos quando tem e quando não tem licitação. O texto da Constituição prevê o seguinte:

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, **as obras, serviços, compra e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A regra é a licitação, para buscar uma disputa melhor, a melhor proposta para a administração pública. Em princípio, isso vale para todo mundo, mas fica de fora o Sistema S, por exemplo. É preciso discutir o Estatuto das Estatais, pois empresas públicas e sociedades de economia mista têm regras próprias, pois precisam ser mais semelhantes e aproximadas às regras do Direito Privado. O que se aplica para o Banco do Brasil deve se aplicar ao Bradesco, pois eles disputam mercado. Não se pode colocar no mesmo “balaio” empresas que prestem serviços públicos, pois elas estão mais perto da lógica da Administração Direta. A prestadora de um serviço público vai para um lado, e a exploradora de atividade econômica, para outro. Tem-se um regramento muito próprio, pois é preciso combinar os Arts. 22, 37 e 173. O Art. 173 trabalha com a existência de lei própria para quem explora atividade econômica. Essa lei demorou muito para chegar. É exatamente por isso que, em um primeiro momento, todos tinham de seguir a Lei n. 8.666, até que a Petrobras se insurgiu, editou um ato normativo próprio, fugindo da Lei n. 8.666 na sua atividade finalística e acabou que isso foi legitimado pelo Supremo.



Sabe-se que a regra é a licitação, e que ficarão de fora dessa regra o Sistema S. Há a superveniência da Lei n. 14.133 para se contrapor à Lei n. 8.666. Havia uma dicotomia entre o Art. 22, dizendo que caberia à União fazer uma lei sobre licitações e o Art. 173, que trataria de modo mais específico quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Dentro desse cenário, tem-se a Lei das Estatais, que é a Lei n. 13.303/2016, que veio antes, inclusive, da nova Lei de Licitações, a Lei n. 14.133. Quando se fala de atividade finalística, ela não precisa de licitação.

Quando se contratava com um município, dentro do contrato, todos os veículos da empresa, obrigatoriamente, precisavam ser registrados e licenciados dentro do município. Quando se pagava o IPVA, um pedaço do dinheiro ficava no estado, e outro no município. Se o carro estava registrado em uma cidade, quem recebia era ela. Quando o prefeito exigia que todos os contratantes de sua cidade licenciassem os carros por essa cidade, ele estava garantindo que teria mais dinheiro para o município – pagava-se dinheiro para a empresa e a empresa dava dinheiro com o IPVA. O Supremo entendeu que isso era inconstitucional.

Houve a discussão de uma lei municipal que impedia a contratação por meio de licitação com o município nos seguintes casos:

- Agentes eletivos;
- Ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança;
- Cônjuge e parentes até o terceiro grau dos sujeitos acima;
- Parentes dos demais servidores municipais.



O STF decidiu que, em relação a agentes eletivos, estava tudo certo; porém, é desproporcional a proibição que alcance vínculo de matrimônio ou parentesco de servidores que não ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Não se pode presumir que esses servidores estejam “de olho” no dinheiro público. Não se pode presumir risco de influência em relação a eles.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
